

1500246-22.2022.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... da menoridade e afastamento do tráfico privilegiado diante do envolvimento em ato infracional por tráfico de drogas e da dedicação à atividade criminosa pelo local da ocorrência do crime e da participação de outras pessoas no ponto, com regime inicial fechado. E a defesa técnica, a absolvição do acusado, ante a falta de provas da autoria delitiva, sendo insuficiente o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500246-22.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500246-22.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE CUNHA DALMOLIN NUNES

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra FELIPE CUNHA DALMOLIN NUNES imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal.

Sustenta a denúncia que, no dia 05 de maio de 2022, por volta das 10h00, na Rua Sete de Setembro, nº 01, Vila Atlântica, nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado, em concurso de agentes com unidade de designios com dois outros indivíduos não identificados, trazia consigo, para fins de tráfico, 08 porções de haxixe, 92 pedras de crack, 35 porções de skunk, 184 porções de cocaína e 100 porções de maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 29 e auto de constatação preliminar de fls. 30/31.

Sustenta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça contra o policial civil Thiago.

Narra que o acusado, querendo praticar a comercialização ilícita de entorpecentes, trazia consigo as supramencionadas drogas, no local conhecido como "Biqueira da Sete". Neste contexto, a equipe da Polícia Civil recebeu informações da mercancia ilícita de entorpecentes naquela localidade, razão pela qual rumou até l. Já no local, e em breve campana, avistaram três indivíduos em situação típica de traficância, sendo que um deles ficava na posse e responsabilidade da sacola plástica em que estavam as drogas servidas aos usuários, enquanto os outros dois faziam a vigilância e segurança. Os policiais decidiram pela abordagem, momento em

que o responsável pela posse das drogas resistiu à ação policial, investindo contra o policial civil Thiago munido de um pedaço de pau. O servidor da lei reagiu à injusta agressão desferindo um disparo de arma de fogo na perna do acusado. Os outros dois criminosos, aproveitando-se da situação, se evadiram para dentro do matagal. O indivíduo que detinha a sacola plástica foi abordado, e identificado como FELIPE. Na supramencionada sacola foram encontradas as drogas anteriormente descritas. As circunstâncias da abordagem, as atitudes dos acusados, o local dos fatos e a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes de naturezas diversas dão conta que as drogas se destinavam ao espúrio comércio.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 47/49).

Laudos acostados a fls. 155/158 e 161/162.

A denúncia foi recebida (fls. 63/64) e o réu, citado (fls. 77/78), apresentou resposta à acusação a fls. 95/122.

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado nega a ocorrência do crime, disser ser usuário e nega ter pego qualquer madeira para agredir o policial.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, ante a suficiência probatória a partir do depoimento policial coerente, ao contrário da versão da testemunha de defesa, incompatível com a própria versão do acusado, ou da tese da autodefesa, não comprovado o motivo de FELIPE estar na cidade, com a valoração na fixação da pena da atenuante da menoridade e afastamento do tráfico privilegiado diante do envolvimento em ato infracional por tráfico de drogas e da dedicação à atividade criminosa pelo local da ocorrência do crime e da participação de outras pessoas no ponto, com regime inicial fechado. E a defesa técnica, a absolvição do acusado, ante a falta de provas da autoria delitiva, sendo insuficiente o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, inclusive com disparo de arma de fogo, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 ou fixação da pena no mínimo e substituição por restritiva de direitos. Puna pela concessão da liberdade provisória.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 147/148 e fls. 149/150.

Fundamentação

Existência e Autoria

A existência do crime da Lei 11.343/06 restou demonstrada pelas provas pericial e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, com massa líquida total de 192,6g e 47,6g, respectivamente.

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades,

gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto ao crack, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o padrão médio de uso no Brasil de 13,42 porções por dia apurado por pesquisa da FIOCRUZ, idealizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, 2014); com o uso de mais de 10 pedras por episódio relatado por 47% de 67 usuários de crack atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010); com o relato de uso de 10 ou mais pedras por 69,5% de 67 usuários de crack atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial de Igrejinha, Taquara e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul (Rogério Lessa Horta et al, Perfil dos usuários de crack que buscam atendimento em Centros de Atenção Psicossocial. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, 2011); e com a média de 73,2 pedras de crack por semana encontrada em pesquisa com 72 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Serra, no Espírito Santo (Janine Andrade Moscon, Avaliação dos padrões de consumo de crack, cognição global e de funções executivas em usuários de ambulatório especializado de alta demanda, Mestrado, UFES, 2013).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

E a existência do crime de resistência e a autoria de ambas as condutas delitivas também restou comprovada pelos demais elementos probatórios colhidos.

Com efeito, os policiais atestaram ter abordado o acusado em via pública, após denúncia anônima de comércio de drogas em conhecido ponto de drogas e tendo presenciado o comércio espúrio envolvendo o acusado. Diante da aproximação policial e dada voz de prisão, disseram que FELIPE reagiu, inclusive golpeando o policial com um pau, em razão do que o agente realizou disparo que o atingiu em sua perna. O policial civil Thiago disse que recebeu informação de que na Rua 7 de Setembro estava ocorrendo o comércio de drogas por uma pessoa, sendo-lhe passadas as características físicas e de vestimenta. A Biqueira da Sete é em via pública, conhecida no meio policial como ponto de venda de drogas. Naquele dia, recebeu a informação de que o indivíduo de roupa preta, com cabelo curto e mexas loiras, de fora da cidade, ficaria em alguns dias da semana lá vendendo droga. Permaneceram em campanha por alguns minutos, mas o local é de difícil de acesso, com mangue e lama, ficando a cerca de 400m, visualizando um grande fluxo de pessoas. A viatura descaracterizada foi rodeada por pessoas do local e tentaram uma estratégia diferente, saindo na frente, sozinho, e Hélio ficou a cerca de 50m dele. Chegando no local, a cerca de 20m, visualizou o indivíduo da denúncia e umas pessoas a seu redor, podendo presenciar que essas pessoas pegavam objetos com ele. Uma pessoa, inclusive, pegou droga de FELIPE logo antes da abordagem. FELIPE estava sentado com uma sacola entre as pernas, de onde retirava a droga. Chegou bem próximo deles –

FELIPE estava com outros dois indivíduos próximos. Quando da retirada do usuário, deu voz de prisão a FELIPE, apontando sua arma, e, de forma inesperada, FELIPE pegou um pedaço de madeira e veio com a intenção de dar em seu braço para desarmá-lo. Os outros dos indivíduos já correram em sua direção, à cintura e ao braço, parecendo que já estavam preparados para agir desta maneira. Para evitar o disparo na região do peito de FELIPE, deu um passo para frente e conseguiu empurrar FELIPE e dar o tiro na sua perna, quando os outros dois saíram em disparada em direção ao mangue. FELIPE foi ao chão e conseguiu contê-lo, chegando seu parceiro. Fizeram os primeiros socorros em FELIPE. Neste momento, a população saiu das casas e começou a tacar objetos em sua direção, chegando uma equipe alguns minutos depois para apoiá-los. Depois de sua prisão, a mãe do acusado foi até a Delegacia e acusou a subtração do celular de FELIPE, mas depois voltou e disse que encontraram o celular com familiares. Fez, ainda, um trabalho de macumba, um ritual religioso com o nome dos policiais e autoridades, na porta da Delegacia, mas preferiu não tomar medidas judiciais. Passou alguns dias no local, anteriormente, mas sem êxito em identificar o traficante dadas as dificuldades geográficas do local, por vezes com a utilização de uma garrafa plástica para intermediar as trocas com alguém de dentro do mangue. Segundo soube, FELIPE seria de fora, mas estaria “trabalhando” na Biqueira há alguns dias. Confirma que mesmo com a arma apontada foi surpreendido com a reação de FELIPE, resistindo à prisão e tentando desarmá-lo, talvez porque imaginou que estivesse sozinho, já que seu companheiro estava mais atrás. Dentro da sacola de FELIPE apreendeu cerca de meio quilo de droga. Chegou de carro nas proximidades, a 400m, visualizando a movimentação, e se aproximou à pé. Não estava de bicicleta, possivelmente havendo algum outro usuário com uma bicicleta. No momento da abordagem estavam os três indivíduos e o usuário comprador anterior havia acabado de sair. Havia poucos moradores na rua diante do horário e, a alguma distância, dos “campanas” da Biqueira. Depois da abordagem é que a rua encheu. Reitera que nada pegou que pertencesse a FELIPE. Realizou dois ou três disparos na hora, a cerca de meio metro de distância. Os moradores começaram a atirar objetos e tiraram fotos de sua pessoa, tudo motivado pela convivência com o tráfico de drogas. Ainda assim, foram só os policiais é que chamaram o SAMU.

O policial civil Hélio atestou que a Biqueira da Sete é local já conhecido do meio policial e recebeu denúncia de tráfico de drogas no local, indo checar no período da manhã, visualizando uma movimentação. Havia um fluxo grande de transeuntes e decidiram verificar o responsável. O policial Thiago, então, foi à frente para verificar a situação à pé, sozinho. Quando viu, FELIPE estava em luta corporal com Thiago, ouviu disparos da arma de fogo e viu FELIPE caindo ao chão e dois indivíduos se evadindo em direção ao mangue. Pediram apoio dos serviços de emergência médica e reforço policial diante da animosidade de populares em razão da atuação policial. Não foram atrás das pessoas que correram para o mangue porque FELIPE estava alvejado e sua prioridade era a preservação da vida, realizando a acomodação e FELIPE e os primeiros socorros. Mudaram a estratégia para preservar a vida, que era o novo objetivo, e não mais fazer a prisão. FELIPE estava sentado em uma cadeira e com as drogas no chão, entre suas pernas. Ele se abaixava e pegava a droga para entregar aos usuários. No momento em que Thiago deu voz de prisão, FELIPE se levantou e, junto com outros dois indivíduos, foram para cima do policial, tudo o que conseguiu visualizar.

Verdade que a testemunha de defesa Carlos retratou dinâmica diversa dos eventos. Disse que tem a posse de terreno na Rua Sete de Setembro, ao lado do conhecido ponto de tráfico de drogas, e, naquele dia, quando lá chegou, os traficantes estavam em frente a seu terreno, mas não era FELIPE que estava lá, entre eles. Os traficantes, em geral, respeitam sua posse, quando vai no terreno fazer os serviços de manutenção e conservação. Havia outros dois traficantes no local. Estava no terreno quando viu FELIPE chegando e, em seguida, um dos policiais, que estava à paisana. Ficou observando, porque sabe que é ponto de tráfico e pode ter que correr. Viu chegar, então, um policial alto, de bicicleta, largá-la no chão, sacar a arma e falar para FELIPE “perdeu!”. Achou curiosa a situação porque havia muita gente na rua, muitas crianças. Era por volta das 09h00-09h30. Quando FELIPE agarrou FELIPE e sua blusa, todos os demais indivíduos na rua correram, incluindo os

usuários. Mesmo segurando FELIPE pela blusa, pelo braço, estando grudado, realizou três disparos, dois em direção aos meninos que correram e um na perna de FELIPE – que estava tentando se esquivar para correr. Após o disparo, o policial correu em direção aos outros indivíduos e chegou um carro preto, descaracterizado, descendo outro policial, com cabelo grisalho, moreno e baixinho, posicionando-se ao lado de FELIPE. Após, o policial alto retornou do mato com uma sacola na mão e deixou do lado de FELIPE e do outro policial. Ficou observando a ação. Depois, os policiais bateram em FELIPE, enfiaram o dedo na ferida da bala, judiaram do “menino” já baleado, e a população do local se reuniu em volta. O resgate demorou para chegar. Viu vídeos do dia e está retratado num deles. Quando chegou o Sr. Milton, o chefe da polícia civil, ele anotou o nome do depoente, porque estava revoltado com a situação, por estarem judiando de FELIPE. Não conhece FELIPE, mas o viu, algumas vezes, talvez duas, no bairro, na rua, mas não no seu terreno. O seu terreno é praticamente em frente ao ponto de droga e chega a pedir para que os traficantes saiam dali, no que é respeitado. Vai sempre no terreno para garantir sua posse. Presenciou toda a abordagem policial. FELIPE estava com umas luzes, meio loirinho, com um casaco cumprido e uma galocha de pedreiro. Quanto às filmagens, disse que elas mostram apenas o resgate e que o depoente estava no local. Perguntado sobre o desencontro do relato diante da versão de FELIPE na audiência de custódia, que sequer reclamou da atitude policial e do disparo, reitera ter visto o policial judiar de FELIPE já atingido. Não foi quem chamou o SAMU, porque tinha muita gente na rua que o fariam. Viu dois meninos trabalhando no ponto, que estavam com uma sacola, e o policial chegou na cola de FELIPE, seguido, e se assustou quando ele atirou a bicicleta no chão. Não sabe o que FELIPE estava fazendo no local, mas supõe que estivesse indo comprar droga.

Extraí-se, porém, do teor do interrogatório que o acusado estava no ponto de venda de drogas e as circunstâncias de sua prisão, com o necessário uso da força e realização de disparo da arma de fogo do policial – o que é de todo estranho à atuação dos agentes nesta Comarca –, bem assim suas condições pessoais apenas corroboram a versão policial. Veja-se que, contando 18 anos da data do fato, teve concedida a remissão como forma de suspensão do processo 0022466-68.2018.8.26.0224, em que se atribuíu a FELIPE a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Depois, diz-se residente em Praia Grande, não havendo senão a genérica alegação a respeito do motivo pelo qual estaria em ponto de venda de drogas em Mongaguá.

De se ressaltar, aliás, que o próprio acusado admite ter encostado no braço do policial enquanto este empunhava a arma de fogo, em versão de todo incrível e que, em verdade, confere maior segurança sobre a resistência à prisão. Note-se que é conduta mesmo incompatível a transeunte estranho à comercialização de drogas, diante da chegada da polícia e abordagem, manter-se próximo ao agente e nele pôr sua mão.

E o relato da testemunha de defesa deve ser visto com ressalvas. A uma porque proveniente de quem, segundo consta, é possuidor-invasor de terreno próximo ao ponto de tráfico. A duas porque incompatível com a própria narrativa do acusado, que nada indicou, inclusive na audiência de custódia, a respeito de qualquer violência ou excesso policial. De se notar que nenhum dos vídeos que existiriam a respeito da abordagem policial vieram aos autos, embora aparentemente de conhecimento da defesa técnica do acusado.

Enfim, inafastável, por isto, concluir pela fidedignidade do relato dos policiais. A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. *mutatis mutandis* HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados.

Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529).

No caso, a narrativa policial está em consonância com os demais elementos de prova. Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

A acusação não logrou demonstrar que o agente seja reincidente, tenha maus antecedentes, se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, razão pela qual aplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, de resto nos termos da manifestação do Ministério Público.

Ao contrário, o único elemento nesse sentido foi a folha de antecedentes, que indica a primariedade dos acusados.

Note-se que a apreensão de quantidade não módica de droga em poder do acusado não é indício suficiente para, isoladamente, permitir se conclua que a acusada se dedica às atividades criminosas, pois daí não se extrai conclusão segura (STF, HC 138138, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016), a menos que se trate de quantidade realmente exorbitante ou que haja outros indícios, o que não é o caso.

Quanto aos antecedentes, diante da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), apenas condenações transitadas em julgado podem ser consideradas, aplicando-se, mutatis mutandis, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (RE 591054, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014). Nesse sentido, particularmente quanto ao disposto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06: STF, RE 1297769 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021; HC 151431, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018.

Ainda que haja outros processos em que se imputa a prática de delitos da Lei 11.343/06, mas sem trânsito em julgado, cabia à acusação demonstrar, neste feito, a ocorrência dos fatos anteriores que pudessem indicar a dedicação à atividade criminosa. Aliás, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.” (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/08/2022, DJe 18/08/2022).

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse

entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa. De se ressaltar, particularmente quanto ao crime de resistência, que a oposição se deu a execução de ordem de prisão em flagrante, em contexto de comercialização de drogas e com o emprego de violência, mas o que não extrapola a reprovabilidade já adequada à pena intermediária adotada.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

O comportamento da vítima, quanto ao crime de resistência, não contribuiu para o delito, cuja censurabilidade não é por isto diminuída.

A natureza e a quantidade da droga são importantes e não autorizam um juízo

favorável ao acusado, pois superiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, nos termos já adotados, mas não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena-base para além da pena intermediária.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão (tráfico de drogas) e 9 meses e 10 dias de detenção (resistência)

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Por conseguinte, observada a preponderância dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, atenuo a pena em 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato.

Note-se que, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo (EREsp 1154752/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 23/05/2012, DJe 04/09/2012; REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), compensam-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

Por fim, na terceira etapa, reduzo a pena do tráfico de 2/3, no patamar máximo do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, do qual não se extrai critério seguro para gradação, em ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal), evitando-se, ainda, inadmissível bis in idem na dupla valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal combinado com o artigo 42 da Lei 11.343/06) na primeira e na terceira etapas.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão (tráfico) e 5 meses e 20 dias de detenção (resistência).

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 800 dias-multa, fixo a pena de multa final em 211 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 49, § 1º, do CP, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Diante da condenação a pena igual ou inferior a 4 anos, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais que não se mostram desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do Código Penal (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal).

É inaplicável ao tráfico privilegiado a previsão constante do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, porque não se trata de crime equiparado a hediondo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016), ao que se curvou o Superior Tribunal de Justiça revendo a tese fixada em recurso repetitivo e cancelando a sua Súmula 512, para assentar que “o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo” (Pet 11.796/DF, Rel.

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da condenação pelo crime de resistência, doloso com violência ou grave ameaça a pessoa, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Tal o que estendo ao crime de tráfico, cometido no mesmo contexto e, assim, diante das circunstâncias desfavoráveis que cercam a conduta, agora com amparo no inciso III daquele preceito.

Também não cabe a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 2 anos a acusado menor de 70 anos e cujas razões de saúde não justificam a medida (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar FELIPE CUNHA DALMOLIN NUNES às penas de reclusão de 2 anos, 1 mês e 10 dias, em regime inicial aberto, e a 211 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de diminuição do parágrafo 4º do mesmo dispositivo; e de detenção de 5 meses e 20 dias, em regime inicial aberto, pela prática do crime do artigo 329, caput, do Código Penal.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e revogo a prisão preventiva, porque incompatível com o regime inicial de cumprimento de pena ora fixado. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal: "a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade." (HC 193996 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020). No mesmo sentido: HC 136397, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016.

Considerando a necessidade de garantir a ordem pública e, sobretudo, de assegurar a aplicação da lei penal, é necessário, adequado e suficiente a concessão da liberdade provisória mediante a determinação de a) comparecimento perante a autoridade policial ou judicial todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) proibição de se ausentar da Comarca por mais de 8 dias sem prévia autorização do Juízo; c) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades. Tudo na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, expeça-se o alvará de soltura clausulado.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA